

1510368-97.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico de drogas, a Lei n.º 11.343/2006 prevê, abstratamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510368-97.2021.8.26.0344 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510368-97.2021.8.26.0344

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2285576/2021 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO, 20914303 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO, 8163/21/504 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO, 2285576 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA, 8163/21/504 - DISE- DEL.SEC.MARÍLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO BALBINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Vistos.

ADRIANO BALBINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, porque no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 14 horas, na Rodovia SP 294, Km 465, neste município e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 376,36g (massa líquida) de Cannabis sativa L, que possui tetrahidrocannabinol, substância que determina dependência psíquica.

Consta que o denunciado trazia consigo, no interior da Penitenciária de Marília, 96 (noventa e seis) invólucros contendo maconha, sendo surpreendido por agentes penitenciários pulando uma cerca viva existente no limite entre as dependências do estabelecimento prisional e uma estrada de terra.

Preso em flagrante delito, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 106/109). A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 142/144). O réu foi citado (fls. 154) e apresentou defesa preliminar (fls. 162/172). Na audiência de instrução virtual realizada em 14 de fevereiro de 2022 foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido inicial. Pugnou pela fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do acusado e o reconhecimento da agravante da reincidência na fase intermediária, sem atenuantes. Requereu o afastamento da causa de diminuição por tráfico privilegiado e a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. Pleiteou a fixação do regime inicial fechado por se tratar de crime equiparado a hediondo e em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu. Entendeu inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e presentes os requisitos legais para manutenção da custódia cautelar (fls. 230/235). O Defensor Público, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pediu a fixação de regime mais brando para cumprimento de eventual pena a ser aplicada em caso de condenação (fls. 239/244). É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 38/39), auto de exibição/apreensão (fls. 40), pelos laudos de constatação (fls. 43/45) e de exame químico-toxicológico (fls. 128/131), atestando a natureza da substância apreendida (Tetrahidrocannabinol), e pela prova oral colhida em juízo.

A testemunha Acir de Marcelo Prata, agente penitenciário, ouvido em juízo, ratificou suas declarações prestadas em solo policial. Afirmou exercer suas atividades na Penitenciária de Marília, sendo que, na data mencionada na denúncia, por volta das 14h, realizava ronda de rotina no perímetro interno e externo do estabelecimento prisional juntamente com o também agente Alexandre Jorge Sato dos Reis, ocasião em que avistaram o acusado Adriano Balbino ultrapassando uma cerca viva existente no limite entre as dependências da penitenciária, saindo do perímetro interno rumo a uma estrada de terra e, em razão da atitude suspeita, abordaram e revistaram o réu, localizando, no interior da calça, junto às genitálias, um saco plástico de cor preta contendo 96 (noventa e seis) porções de maconha, também envoltas no mesmo material. Relatou que, questionado sobre os fatos, o réu disse que foi buscar fora da Penitenciária a droga, porém não forneceu detalhes, de modo que o depoente lhe deu voz de prisão e o conduziu até a unidade policial. Disse integrar o GIR – Grupo de Intervenção Rápida. Acrescentou que o réu já havia passado na unidade anteriormente, sendo que, da última vez, não soube precisar a data de sua inclusão. Aduziu não ter conhecimento se o réu recebia visitas.

Por sua vez, a testemunha Alexandre Jorge Sato dos Reis, agente penitenciário, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou exercer suas atividades na Penitenciária de Marília, sendo que, no dia dos fatos, realizava ronda de rotina juntamente com o agente Acir, ocasião em que avistaram o acusado Adriano Balbino passando por baixo de uma cerca viva, que também contém arame farpado, próximo ao pomar, no limite entre as dependências do estabelecimento prisional. O réu correu até uma vegetação, localizada num barranco do outro lado da estrada de terra circunvizinha, e retornou rapidamente para dentro da Unidade, de modo que o abordaram e revistaram, sendo certo que ele estava com um volume dentro da cueca. Relatou que o réu afirmou que o volume lhe pertencia e que tinha sido deixado por uma pessoa na vegetação aludida para que o réu fosse buscar. Respondeu que se tratava de um saco plástico de cor preta contendo porções de maconha, não se recordando a quantidade, que era, contudo, expressiva.

Ora, não há motivos para desmerecer os depoimentos dos agentes de segurança, sobretudo porque o réu não demonstrou que as testemunhas quisessem prejudicá-lo gratuita e deliberadamente. Vale dizer que inexiste nos autos dados concretos no

sentido de que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob compromisso, quisessem mentir. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, *mutatis mutandis*, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.4.2020).

Na fase administrativa, o réu Adriano Balbino negou a prática do crime. Afirmou desconhecer a droga apreendida. Aduziu que cumpria pena no regime semiaberto da Penitenciária de Marília-SP e negou que os agentes penitenciários tenham encontrado droga em seu poder no dia 19 de outubro de 2021. Relatou que, no período da tarde, de fato pulou o alambrado do mencionado estabelecimento prisional, o qual fica ao lado de uma estrada de terra, porém não pegou droga nenhuma naquele local (fls. 7). Por ocasião de seu interrogatório judicial, alegou que saiu para trabalhar na sub-portaria, de modo que possuía acesso à área externa da unidade prisional. Disse que, na região do pomar, se deparou com um cartucho plástico na cor preta e, curioso, abriu-o, constatando que continha folhas e pedras. Afirmou que colocou o cartucho na cintura para sair da região do pomar, localizado próximo às residências dos diretores do estabelecimento prisional, por se tratar de um local que não tem livre acesso, momento em que foi abordado por agentes penitenciários, para quem explicou que ali se encontrava para fazer necessidades e colher frutos. Alegou que os funcionários o imobilizaram e o conduziram até a sede do GIR, onde lhe mostraram fotografias de outros sentenciados e questionaram quem seria o proprietário das drogas. Negou trazer consigo as drogas. Afirmou ter apenas passado pelo portão de acesso ao pomar, mas contestou ter transposto a cerca viva.

Como se vê, não obstante os argumentos defensivos, a prova coligida é robusta e sustenta o decreto condenatório do réu. Isso porque a negativa apresentada por ele em Juízo restou isolada nos autos, não encontrando qualquer respaldo nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual.

Os depoimentos dos agentes penitenciários, por sua vez, foram coesos e harmônicos entre si, demonstrando que o denunciado cumpria pena em regime semiaberto e foi avistado transpondo uma cerca viva existente no limite entre as dependências do estabelecimento prisional e uma estrada de terra. Abordado e revistado, localizaram, no interior da calça do réu, um saco plástico de cor preta contendo 96 (noventa e seis) porções de maconha, também envoltas em plástico de cor preta. Inegável que a droga foi apreendida com o acusado, amoldando-se, a conduta, à figura típica de trazer consigo disposta no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. De fato, o acusado conduzia pessoalmente a droga. E, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado envolvendo o mesmo objeto material, eventual pluralidade de condutas não descaracteriza o crime, de modo que irrelevante se o acusado adquiriu primeiramente o entorpecente ou o encontrou fortuitamente, na medida em que as condutas denotam sucessão de fases de um mesmo ilícito penal. Diante desse cenário, não há se cogitar insuficiência probatória (*in dubio pro reo*), atipicidade da conduta ou crime tentado, tampouco em desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 ante a quantidade de droga encontrada em posse do acusado.

A imputação delimitada na denúncia é no sentido de que o acusado trazia consigo droga, que determina dependência química e física, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, núcleo contido no tipo incriminador do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, delito de caráter permanente, cuja consumação ocorre no momento em que o agente realiza a conduta típica, prolongando-se no tempo durante o período em que o réu estava com a droga, autorizando, inclusive, a prisão em flagrante delito, como ocorreu no caso versado. Por ocasião do procedimento de revista, decerto que o réu já trazia consigo a droga, restando consumada a infração penal.

Realmente, se o sujeito ativo é preso trazendo consigo droga, responde pela forma consumada e não por tentativa de ingresso em estabelecimento prisional na posse dela.

Outrossim, a intenção do tráfico ilícito de drogas restou indubitável em razão da quantidade da droga apreendida, forma de acondicionamento e comportamento do

acusado antes da apreensão. O réu cumpria pena em regime semiaberto junto à Unidade Prisional de Marília-SP, sendo que recebeu, por meios não devidamente esclarecidos, a droga para o fim de entrega a consumo de terceiros, transpondo a cerca viva existente nos limites do estabelecimento prisional para nele ingressar trazendo consigo a droga, denotando, inclusive, seu intento em driblar o procedimento de revista nas hipóteses de retorno à Unidade após a prestação de serviços externos. Além disso, improvável que a quantidade de droga apreendida e a forma como embalada seja simplesmente destinada ao consumo do acusado. Urge anotar, ainda, que a jurisprudência é no sentido de que "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Destaca-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de que "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp n.º 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6.T., j. 10.6.2014).

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal. Para o crime de tráfico de drogas, a Lei n.º 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atentando aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que os maus antecedentes (fls. 48/60 e fls. 61/101) e a grande quantidade de drogas autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram maior grau de culpabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase de aplicação de pena, por ser reincidente (fls. 61/100), exaspero a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do estabelecimento prisional onde cumpria pena em regime semiaberto, razão pela qual agrava-se a reprimenda em 1/6 (um sexto). Portanto, fixa-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 11 (onze) e 8 (oito) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumpridas inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2.º, alínea "a" e § 3.º, do Código Penal, considerando a recidiva criminosa quando o acusado cumpria pena em regime semiaberto, sendo ineficaz a concessão de liberdade desvigiada, até mesmo porque a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, na forma do artigo 52 da Lei de Execuções Penais e enseja a regressão de regime prisional e perda de parte dos dias remidos, conforme prescrito nos artigos 118 e 127, ambos do mesmo diploma legal. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena são incabíveis por falta de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo a que aludem os artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente em crimes dolosos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar ADRIANO BALBINO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 (setecentos e noventa e

três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado, nega-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, ainda mais porque permaneceu preso durante todo o processo para garantia da ordem pública, eis que multirreincidente, nada justificando a soltura após a condenação. Recomende-se na prisão em que se encontra recolhido.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, letra "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intimem-se pessoalmente para efetuar o recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando suspensa a exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP, para atendimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 4 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA